ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE JURÍDICA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO BUTANTAN
ASSUNTOS: COVID-19. AQUISIÇÃO DE VACINA FUNDAMENTADA NA MP 1.026 DE 2021
VALOR:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSA. CORONAVÍRUS. Aquisição de vacina antes do registro ou autorização de uso emergencial da Anvisa. Medida Provisória 1.026, de 6 de janeiro de 2021. Contrato Administrativo nº 5/2021. Procedimento simplificado. Possibilidade jurídica condicionada ao atendimento das recomendações.

RELATÓRIO

1. Trata-se de processo administrativo encaminhado a este órgão consultivo, para análise e manifestação acerca da possibilidade de convalidação de contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 2º, I da Medida Provisória 1.026 de 6 de janeiro de 2021, tendo como objeto a aquisição de vacina adsorvida COVID-19 (INATIVADA) CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL , no valor de R$ 2.677.200.000,00 (dois bilhões, seiscentos e setenta e sete milhões duzentos mil reais) realizada com a Fundação Butantan, por meio do Contrato nº 5/2021.

2. Os presentes autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, pertinentes à presente análise:

- Ofício Butantan 0018476182
- Nota Técnica 8 0018476455
- Nota Técnica 9 0018476460
- Nota Técnica 8 0018477057
- Termo de referência 0018493366
- Contrato 0018477781
- Mapa de Riscos 0018485556

3. Por razões de economia processual, documentos não mencionados no item anterior serão devidamente referenciados ao longo do parecer.

4. É o relatório.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Dos limites da análise jurídica

5. A atividade de exame e aprovação de minutas de contratos e dos atos pelos quais se vai decidir a dispensa de licitação pelos órgãos de consultoria da Advocacia-Geral da União é prévia, consoante o art. 11, inciso VI, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar n.º 73, de 1993. Dessa maneira, não há determinação legal a impor a fiscalização posterior de cumprimento de recomendações feitas pela unidade jurídico-consultiva. Além do mais, na eventualidade de o administrador não atender as orientações do órgão consultivo, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta.

6. Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva – BPC n° 7, que assim dispõe:

7. A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento. (Manual de Boas Práticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01, de 2 de dezembro de 2016)

8. Feita a ressalva, passamos à análise estritamente jurídica do presente processo.

Possibilidade de Convalidação

9. Observa-se que o Contrato Administrativo n° 05/2021 foi firmado sem prévia oitiva desta Consultoria Jurídica, em desacordo com o previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93:

> Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

10. A prévia e obrigatória análise das minutas de editais e de contratos (ou instrumentos similares), incluindo seus aditamentos, têm por fim evitar a descoberta tardia de defeitos jurídicos. Todavia, essa exigência, se não cumprida no momento em que a lei descreve – prévia – não é um fim em si mesmo, sendo tal omissão passível de saneamento.

11. Entretanto, apesar de contrariar a legislação citada, entende-se, tal qual presente no Manual sobre licitações e contratos do Tribunal de Contas da União, que "os atos que apresentarem defeitos sanáveis, isto é, aqueles que não evidenciem danos ao interesse público nem prejuízos a terceiros poderão ser convalidados pela própria Administração"[1].

12. É o que dispõe a Lei n.º 9.784/99, art. 55:

> Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

13. Ademais, Marçal Justen Filho[2] explica que:

> Deve reconhecer-se que a regra do parágrafo único destina-se a evitar a descoberta tardia de defeitos. Como a quase totalidade das formalidades, a aprovação pela assessoria jurídica não trata de formalidade que se exaure em si mesma. Se o edital e as minutas de contratação forem perfeitos e não possuírem irregularidades, seria um despropósito supor que a ausência de prévia aprovação da assessoria jurídica seria suficiente para invalidar a licitação. Portanto, o essencial é a regularidades dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica. Com isso, afirma que a ausência de observância do disposto no parágrafo único não vicia o procedimento se o edital ou o contrato não apresentavam vício. Configurar-se-á apenas a responsabilidade funcional para os agentes que deixaram de atender à formalidade.

14. Portanto, passar-se-á a análise do contrato, para fins de convalidação em caso de ser constatada sua regularidade.

1.2 Breve contextualização sobre a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus: aspectos legais e previsão de hipótese temporária de dispensa de licitação.

15. Como é notório, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Já no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, passou a ser caracterizada como uma pandemia, em razão de ter a doença atingido diversos países do mundo, em três continentes ou mais.

16. Em âmbito mundial, iniciou-se uma verdadeira corrida para a aquisição de vacinas, no intuito de imunizar a população contra essa nova doença. Nesse contexto, tendo em vista a necessidade de o Brasil garantir a aquisição das vacinas em desenvolvimento, editou-se a Medida Provisória 1026 de 6 de janeiro de 2021, que criou nova hipótese de dispensa de licitação, em seu art. 2º, que assim dispõe:

> Art. 2º Fica a administração pública direta e indireta autorizada a celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa de licitação, para:
>
> I - a aquisição de vacinas e de insumos destinados a vacinação contra a **covid-19**, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial; e
>
> II - a contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária, treinamentos e outros bens e serviços necessários a implementação da vacinação contra a **covid-19**.

17. Considerando a excepcionalidade do regramento posto, é possível concluir que as disposições da Medida Provisória 1026/2021 - em especial, no que interessa ao presente exame, as normas sobre dispensa de licitação -, são aplicáveis apenas e tão somente às expressas situações abrangidas no novel texto legal, nas quais resta afastada, total ou parcialmente, a incidência do regime jurídico geral de contratação pública, previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

18. De acordo com o Manual de Boas Práticas Consultivas, da Consultoria-Geral da União, no enunciado 11:

19. As licitações e contratações sustentáveis constituem política pública relevante para a Administração, cabendo aos Órgãos Consultivos, mediante suas práticas e manifestações nos processos submetidos a seu exame, fomentar e sedimentar a sua instrumentalização para a construção de um meio ambiente sustentável.

20. Tendo por fundamento os compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, os artigos 3º e 225, da Constituição Federal e legislação, há um poder-dever do gestor público na realização de licitações sustentáveis, considerando aspectos ambientais, sociais, econômicos e de acessibilidade. Assim, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável é diretriz a ser observada na licitação (artigo 3o, "caput", Lei 8666/93), ao lado da garantia de observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

21. O Decreto 7.746/12, alterado parcialmente pelo Decreto 9.178/17, regulamentou o artigo 3º, da Lei 8.666/93 e, na efetivação do desenvolvimento nacional sustentável pelas licitações, o órgão assessorado deve atentar se na contratação incidem critérios e práticas (artigos 3º e 4º) de sustentabilidade.

22. Os critérios e práticas de sustentabilidade devem constar como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial, de acordo com o disposto no inciso IV do caput do artigo 30 da Lei 8.666/93. Em subsídio:

> 1.10. Dar ciência à (...) sobre as seguintes impropriedades: 1.10.2. falta de aplicação de critérios e práticas de sustentabilidade, que contribuem para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em suas contratações, o que afronta o art. 3º da Lei 8666/1993. ACÓRDÃO Nº 32/2015 - TCU - 2ª Câmara . Processo TC-034.526/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) relator Raimundo Carreiro
>
> (...) as chamadas licitações sustentáveis constituem importante instrumento a ser adotado pelas entidades públicas para, utilizando seu significativo poder de compra, induzir o setor produtivo a adotar processos de produção ambientalmente mais sustentáveis.
>
> (Acórdão 0691-04/13-2 - 2ª. Câmara)

23. Uma licitação é sustentável nas diversas fases da contratação:

> a) previamente no planejamento do que (especificação do objeto) e como contratar (obrigação da contratada),

b) na observância da legislação de sustentabilidade e acessibilidade incidente,

c) na execução contratual e

d) no gerenciamento socioambiental adequado das embalagens e resíduos decorrentes da contratação.

24. **No caso em comento, deverá a área observar se é cabível atender alguma das recomendações nas fases processuais e se possível, deverá inserir na referida aquisição, ou justificar a não incidência. O item 15 do TR definiu o seguinte critério de sustentabilidade ambiental:**

> Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998 e da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000 é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permidos pelo Protocolo de Montreal, conforme argo 1º, parágrafo único, do Decreto nº. 783, de 1998, e o argo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

25. **Deve a área avaliar se a previsão é suficiente em relação ao objeto da contratação.**

1.3 Da dispensa de licitação prevista no art. 2º da Medida Provisória 1026 de 6 de janeiro 2021

26. Como explanado em tópico anterior, a MP 1026/2021 em seu art. 2° estabeleceu a dispensabilidade do procedimento licitatório para a aquisição de vacinas e de insumos destinados a vacinação contra a **covid-19**, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial, bem como para contratação de bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária, treinamentos e outros bens e serviços necessários a implementação da vacinação contra a **covid-19**.

27. No presente caso, observa-se que o objeto da contratação se insere no inciso I do art. 2º do normativo, consistindo em aquisição de vacinas contra covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial.

28. Para as contratações acima, conforme dispõe o art. 3º da MP 1026, presumem-se atendidas as condições de ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2); e a necessidade de pronto atendimento à situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2). Vejamos:

> Art. 3º Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Medida Provisória, presumem-se comprovadas:
>
> I - a ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2); e
>
> II - a necessidade de pronto atendimento à situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).

29.

30. Dessa forma, nos casos previstos no art. 2º , fica dispensada a comprovação dos requisitos acima mencionados, já que a lei, por bem, entendeu que eles já foram devidamente atendidos.

31. Por outro lado, o artigo 26 da Lei 8.666/93 afirma o seguinte:

> Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
>
> Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
>
> I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)
>
> II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
>
> III - justificativa do preço.

> IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

32. Também o art. 2º, §1º da MP assim determina:

> § 1º A dispensa da realização de licitação para a celebração de contratos ou de instrumentos congêneres de que trata o **caput** não afasta a necessidade de processo administrativo que contenha os elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação e à justificativa do preço.

33. Deste modo, entende-se que os autos deverão ser instruídos com a razão da escolha do fornecedor, que nesse caso em específico se confunde com a necessidade de constar nos autos elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação (o porque da opção de aquisição da referida vacina, em detrimento de outras em desenvolvimento), bem como a justificativa do preço, que será abordada em tópico específico.

34. **Assim, apesar de presumido o atendimento do pressuposto da emergência e da necessidade de pronto atendimento caracterizadores da dispensa de que trata a MP 1026 a justificativa da contratação deverá ser providenciada pela própria Autoridade ora assessorada, que decerto detém os conhecimentos técnicos necessários para tanto.**

FORMALIDADES PREVISTAS NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.026 DE 2021

35. Analisada a questão referente à possibilidade de contratação mediante dispensa de licitação prevista no art. 2º, I , cumpre agora examinar a observância dos requisitos impostos no próprio normativo,

36. Vale mencionar que, no caso das referidas dispensas, foram criadas formalidades no procedimento, de modo que, por ser específico à situação em tela, não deverá mais ser aplicado o art. 26, da Lei nº 8.666, de 1993, **salvo no que for cabível.** Nos subtópicos seguintes passaremos a abordar esses requisitos.

a) Termo de Referência/Projeto Básico Simplificado

37. Nas hipóteses de contratações que envolvam o objeto do presente parecer referencial, o art. 6º da MP 1.026 , prevê que poderá a Administração Pública apresentar Termo de Referência ou Projeto Básico simplificado com o objetivo de desburocratizar o procedimento, em face da celeridade exigida nesses casos.

38. Importa ressaltar que a simplificação não significa que não conterá os elementos básicos e norteadores das contratações. O §1º do mesmo artigo estabelece os requisitos que o documento deverá conter, conforme se verifica abaixo:

> Art. 6º Nas aquisições ou contratações de que trata esta Medida Provisória, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
>
> § 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no **caput** conterá:
>
> I - declaração do objeto;
>
> II - fundamentação simplificada da contratação;
>
> III - descrição resumida da solução apresentada;
>
> IV - requisitos da contratação;
>
> V - critérios de medição e de pagamento;
>
> VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
>
> a) Portal de Compras do Governo Federal;
>
> b) pesquisa publicada em mídia especializada;
>
> c) sites especializados ou de domínio amplo;
>
> d) contratações similares de outros entes públicos; ou
>
> e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
>
> VII - adequação orçamentária.

39. No presente caso, o termo de referência simplificado encontra-se no documento SEI 0018476562 , o qual analisaremos em tópico específico.

b) Estimativa de preços

40. Com relação à justificativa do preço, trata-se de um dever imposto ao Administrador, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por consequência, probidade e moralidade ao ajuste.

41. A necessidade da justificativa do preço decorre dos princípios da motivação, da economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa necessidade de bem atender o interesse público, por meio de uma gestão eficiente e proba dos recursos públicos. Trata-se de dever da Autoridade assessorada, responsável pela gestão dos recursos públicos a ela confiados. Ou seja, por força do previsto no art. 25, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, deve ser evitada a qualquer custo a configuração de superfaturamento de preços, que constitui causa de vício na contratação:

> Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
>
> [...]
>
> § 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

42. Via de regra, devem ser observados os procedimentos instituídos pela IN/SLTI/MPOG nº 73 de 5 de agosto de 2020, que estabeleceu "parâmetros" específicos para o balizamento dos preços.

43. **No entanto, por força da MP 1.026, a exigência de estimativa de preços é excepcionalmente relativizada no §2º, do art. 6º, devido às possíveis dificuldades em se obter as estimativas de forma célere e que reflitam a realidade do mercado dentro dos exíguos prazos que dispõe este Ministério da Saúde para a contratação.**

44. No mesmo sentido o permissivo constante no §3º, do art. 6º, diante da urgência das contratações decorrentes da MP 1.026, muito embora tenha sido possível a obtenção de pesquisa de preços realizada com base no inciso VI do mesmo artigo, haverá situações em que, com as oscilações de preços no mercado (agravadas com a pandemia), não restará outra opção à Administração Pública a não ser a contratação por valores superiores àqueles obtidos na própria estimativa então realizada, desde que se comprove negociação prévia com os fornecedores na ordem de classificação e que haja fundamentação. Vejamos:

> VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
>
> a) Portal de Compras do Governo Federal;
>
> b) pesquisa publicada em mídia especializada;
>
> c) sites especializados ou de domínio amplo;
>
> d) contratações similares de outros entes públicos; ou
>
> e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
>
> VII - adequação orçamentária.
>
> § 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, poderá ser dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º.
>
> § 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições:
>
> I - negociação prévia com os demais fornecedores, de acordo com a ordem de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e
>
> II - fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente.

45. Dessa forma, em que pese a não aplicação da IN/SLTI/MPOG nº 73, de2020, os preços obtidos devem ser devidamente justificados em cada contratação.

46. **No presente caso, não se observou nos autos a existência da estimativa de preços na forma do art. 6º, VI, nem mesmo justificativa para a sua dispensa excepcional, na forma do §2ª do art. 6º, o que deverá ser sanado. Relembra-se que a justificativa do preço é indispensável nos processos de dispensa de que trata a MP 1026 de 2021, conforme art. 2º, §1º.**

47. **No presente caso, inclusive, a justificativa de preço deverá levar em consideração também a eficácia da vacina, levando em conta os possíveis cenários.**

c) Matriz de alocação de risco entre contratante e contratado

48. O artigo 5º *caput*, traz uma inovação para as contratações regidas pela Medida Provisória 1.026 de 2021. De acordo com o dispositivo, será obrigatória a previsão de matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado, na hipótese de aquisições e contratos acima de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

49. Primeiramente, é preciso entender o que seria a "matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado". Inicialmente, cabe ressaltar que não se trata do instrumento denominado mapa de riscos de que trata a IN 05/2017 e outros normativos relativos à planejamento da contratação. A matriz de alocação de risco entre contratante e contratado não conta com previsão na legislação geral de licitações e contratos, de forma que teremos que buscar o seu conteúdo em outras normas.

50. Tendo em vista a lacuna legislativa, deve-se utilizar, no caso, a analogia, conforme determina o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, buscando no ordenamento jurídico pátrio, normativos que possam ter aplicação às presentes contratações.

51. A Lei 13.303/2016 que "Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.", estabelece o seguinte:

> Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições:
>
> [...]
>
> X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
>
> a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
>
> b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
>
> c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.
>
> [...]
>
> Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:
>
> [...]
>
> X - matriz de riscos.
>
> [...]
>
> Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
>
> [...]
>
> § 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

52. Também pode-se utilizar como parâmetro os princípios gerais do Direito e invocar o texto do projeto aprovado no Congresso Nacional da nova Lei de Licitações e Contratos (PROJETO DE LEI N° 4253, DE 2020), é prevista tal matriz da seguinte forma:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> [...]
>
> XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

[...]

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso ocorra durante a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I – às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

II – à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual;

III – à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Art. 91. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabelecem:

[...]

IX – a matriz de risco, quando for o caso;

[...]

CAPÍTULO III

DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Art. 102. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Serão preferencialmente transferidos ao contratado os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

> I – às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 123 desta Lei;
>
> II – ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
>
> § 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.

53. Desta forma, a matriz de riscos pode ser entendida como a "cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação".

54. Também o Tribunal de Contas da União já decidiu pela necessidade de previsão de matriz de riscos em editais e instrumentos contratuais, em casos em que o objeto contenha riscos envolvidos, conforme se observa de trecho do Acórdão 1310/2013 (Plenário):

> (..)
>
> 9.1.1) preveja doravante, nos empreendimentos licitados mediante o regime de contratação integrada, conforme faculta o art. 9º da Lei 12.462/2011, *"matriz* de *riscos"* no instrumento convocatório e na minuta contratual, para tornar o certame mais transparente, fortalecendo, principalmente, a isonomia da licitação (art. 37, XXI da Constituição Federal; art. 1º, §1º, IV da Lei nº 12.462/2011) e a segurança jurídica do contrato;

55. **No presente caso, o valor da contratação é de R$ 2.677.200.000,00 (dois bilhões, seiscentos e setenta e sete milhões duzentos mil reais), sendo indispensável a elaboração da matriz de riscos, não tendo sido verificada nos autos a sua elaboração.** Ademais, tendo em vista que se trata de aquisição de vacina antes do registro na ANVISA e até mesmo da autorização para uso emergencial, recomenda-se que haja previsão dos riscos, especialmente no que diz respeito a: efetividade das vacinas, a qual pode inclusive impactar no quantitativo necessário à imunização da população e na vantajosidade; a possibilidade de não ser concedido pela Anvisa a autorização para uso emergencial e/ou o registro, deverá ser prevista a hipótese de não concessão do registro definitivo após autorização de uso emergencial e pagamento e de que forma será realizado o devido compartilhamento dos riscos, nesse caso ademais, aspectos relacionados à logística, transporte e armazenagem, nos casos de necessidade de devolução em face do não registro, bem como possibilidade de entrega só se realizar após a autorização de uso temporária, tendo em vista que de acordo com o art. 13, §2º da MP: A aplicação das vacinas de que trata o **caput** somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o registro de vacinas concedidos pela Anvisa.

d) Da dispensa de elaboração de estudos preliminares e do gerenciamento de riscos

56. A fase de planejamento da contratação encontra-se prevista e disciplinada no Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, e, em relação aos serviços, também na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, da então Secretária de Gestão do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sendo concretizada, em regra, ao longo das seguintes etapas: (i) documento para formalização da demanda; (ii) estudos preliminares; (iii) gerenciamento de riscos; e (vi) projeto básico ou termo de referência, a depender do caso.

57. Considerando a necessidade de realizar contratações públicas mais céleres, com procedimentos internos simplificados, o art. 4º da MP 1.026/2021, estabeleceu que a elaboração de estudos preliminares não se faz necessária nas aquisições e contratações de que trata a medida provisória, quando se tratar de bens e serviços comuns.

58. *Contrario sensu,* caso a contratação com base na Medida Provisória 1.026, de 2021, tenha por objeto bens ou serviços **especiais** (art. 3º, inciso III, do Decreto n.º 10.024/2019), que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não possam ser objetivamente definidos por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado (art. 3º, inciso II, do do Decreto n.º 10.024/2019), será necessária a elaboração dos estudos preliminares pela Administração.

59. Como se sabe, é do setor técnico competente a definição do bem ou serviço como comum ou especial, e com base nessa premissa, o Advogado-Geral da União editou a Orientação Normativa n° 54, que assim dispõe:

> COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O OBJETO LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O DEVIDO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE LICITATÓRIA APLICÁVEL.

60. **No caso, não se verifica nos autos declaração administrativa acerca da natureza comum ou especial do objeto da contratação, o que deverá ser providenciado, com a consequente elaboração, na segunda hipótese, dos**

estudos preliminares.

61. Tendo em vista que o contrato terá valor superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões), se faz necessário o gerenciamento de riscos, tendo em vista que apenas encontra-se dispensado pelo art. 5º, Parágrafo Único da MP 1.026 /2021 em contratos abaixo dessa alçada.

62. **Nos autos, verifica-se a existência de mapa de riscos (0018485556) , no entanto, em relação a esse, recomendamos a adoção do modelo constante no Anexo IV da IN 05/2017, indicando a probabilidade, impacto e respectivas ações de prevenção e contingencia.**

e) Acréscimos e supressões ao objeto contratual

63. Em relação aos acréscimos e supressões ao objeto contratado, estabelece o art. 9º, da MP 1. 026/2021

> art. 9º Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Medida Provisória, a administração pública direta e indireta poderá prever que os contratados sejam obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato

64. Diante da imprevisibilidade da situação emergencial, a Administração Pública está autorizada a prever, nos contratos de aquisição, percentuais de acréscimos e supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Tal medida é de suma importância, tendo em vista que os quantitativos das contratações serão estabelecidos em razão de modelos matemáticos para a propagação e gravidade dos casos de infecção pelo coronavírus.

65. Tais modelos matemáticos são atualizados todos os dias com os novos dados da situação do país, de forma que não é possível prever com exatidão os quantitativos que serão demandados. Dessa forma, o legislador flexibilizou o disposto no artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, dando maior margem para que a Administração suprima ou acresça os quantitativos contratados, de forma a realizar o correto dimensionamento do objeto frente às necessidades do sistema de saúde.

66. Outrossim, em que pese ser uma faculdade do gestor, recomenda-se que em todos os contratos seja estabelecido tal possibilidade de alteração, salvo quando pela natureza do bem ou insumo de saúde a Administração Pública entender que tal previsão afastará a participação do mercado, devendo ser observado caso a caso.

67. **Desta forma, deve-se justificar a não previsão desta possibilidade.**

e) Requisitos de habilitação

68. Como se sabe, a habilitação possui como função definida pelo Constituinte, nos termos do artigo 37, inciso XXI, o qual determinou que os requisitos para a habilitação devem ser, apenas, os necessários à garantia do cumprimento das obrigações contratuais.

69. O artigo 27 da Lei nº 8.666/93 lista os parâmetros de habilitação exigíveis, conforme elenco dado pelos artigos 28 a 31. Ocorre que, embora essa não seja uma prática comum na atuação conservadora da administração pública, tais parâmetros não precisam e nem devem ser exigidos em toda licitação ou contratação pública, mas apenas na medida necessária à garantia do cumprimento das obrigações contratuais, como definiu o constituinte.

70. Diante da situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus, o legislador entendeu que, em situações excepcionais, alguns requisitos podem ser dispensados. Nesse sentido, dispõe a MP 1026/2021:

> Art. 7º Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do **caput** do art. 7º e do §3º do art. 195 da Constituição.

71. Esta inovação legislativa permite o afastamento, excepcional, mediante justificativa, em geral, da apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou de outros requisitos de habilitação,

ressalvando a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do **caput** do art. 7º da Constituição.

72. Cabe registrar, contudo, que, tratando-se de fornecimento de bens para pronta entrega, o legislador geral já admite a dispensa dos parâmetros de habilitação. Convém lembrar, inclusive, que a autorização dada pelo legislador não foi condicionada, admitindo a não exigência de quaisquer dos documentos exigidos pelos artigos 28 a 31. Senão, vejamos:

> Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
>
> § 1º **A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão (grifo nosso)**

73. Obviamente, mesmo com a autorização dada pelo legislador, não é, em princípio, conveniente abrir mão de requisitos indiciários do cumprimento das obrigações pactuadas. Por outro lado, justifica-se o afastamento das exigências que não possuem tal função.

74. No presente caso, consta nos autos a consulta consolidada SICAF, TCU e Cadin, que se destinam à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da futura contratada. R**ecomenda-se a complementação, de modo a constar a declaração de que não emprega menor nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição federal.**

75. **Ademais, o item 4.11 do TR prevê requisitos de qualificação técnica os quais deverão ser carreado aos autos.**

g) inaplicabilidade do artigo 26 da Lei 8.666 - inclusive no que toca à necessidade de publicação da contratação na imprensa oficial e ratificação do reconhecimento da dispensa;

76. O art. 26 supracitado prevê o seguinte:

> Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

77. O art. 26 é claro ao dispor a sua aplicabilidade às dispensas previstas no art. 24 da Lei nº 8.666/93, de modo que não é razoável dizer que ele incidiria diretamente sobre a dispensa do art 2º da MP 1.026. O que seria possível afirmar é que poderia haver uma eventual aplicação analógica da regra prevista no art. 26 às contratações regidas pela norma.

78. A analogia se aplica quando há lacunas no texto normativo e quando se tratar das mesmas circunstâncias e da mesma previsão. Essa última ressalva é importante, porque inobstante o art. 2º possa eventualmente ser inspirado no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, as circunstâncias que envolvem um e outro são bastante peculiares (um está em uma norma permanente e o outro em uma lei temporária para tratar de uma emergência internacional sem precedentes), de modo que não seria razoável simplesmente presumir que o que seria aplicável a um o seria também a outro.

79. Quanto às medidas de publicação, a MP 1.026 no art. 2º, §2º , assim dispõe:

> § 2º Será conferida transparência ativa a todas as aquisições ou contratações realizadas nos termos do disposto nesta Medida Provisória, no prazo de cinco dias úteis, contado da data da realização do ato, em sítio eletrônico oficial na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no qual serão divulgados:
>
> I - o nome do contratado e o número de sua inscrição junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou identificador congênere no caso de empresa estrangeira que não funcione no País;
>
> II - o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação;
>
> III - o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;

> IV - a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação do serviço;
>
> V - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista;
>
> VI - as informações sobre eventuais aditivos contratuais;
>
> VII - a quantidade entregue ou prestada em cada ente federativo durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços; e
>
> VIII - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine, se houver.

80. Deste modo, não havendo lacuna quanto a esse aspecto, entende-se inaplicável a exigência de publicação na impressa oficial, devendo a publicação observar unicamente o que dispõe o art. 2º, §²º acima transcrito.

81. O mesmo raciocínio se aplica aos aditamentos contratuais, os quais devem seguir a mesma sorte do principal, até para que haja unidade na forma de divulgação da mesma informação.

DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS APLICÁVEIS

82. Analisadas as exigências específicas impostas pela lei, cumpre agora examinar a instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações administrativas.

83. Assim, sem prejuízo dos documentos que devem constar nos processos, é necessário que a Autoridade assessorada verifique e vele para que seja observada a devida instrução destes autos, atentando para as exigências da Lei nº 8.666, de 1993.

a) Justificativa da Contratação

84. Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar no mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da contratação, ou dos quantitativos estimados.

85. Ressalte-se ainda que a justificativa da contratação deve compreender, ao menos quando possível, os quantitativos estimados da aquisição condizente com o consumo/utilização prováveis do órgão, aferida mediante adequadas técnicas para tanto, em conformidade com o que dispõe o art. 15, §7º, inc. II, pois dela dependerá o cálculo do valor contratual.

> Art. 15 [...]
>
> § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
>
> [...]
>
> II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;"
>
> Nota Explicativa: No caso de serviços, no anexo III da IN Nº 05, de 2017, item 3.1, letra "a" consta a diretriz no sentido de que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da contratação.

86. Via de regra, não cabe em uma manifestação jurídica como a que ora se procede, imiscuir-se no mérito da justificativa apresentada pela Autoridade, de tal sorte que, as considerações ora feitas devem ser encaradas apenas como um alerta para que, caso a Autoridade julgue oportuno, em prol da sua própria segurança, determine diligências ou complementação de justificativas apresentadas.

87. No entanto, na análise da justificativa apresentada aos autos por meio das Notas Técnicas 8 e 9 (0018476455; 0018476460) convém recomendar a sua complementação. De início a Nota Técnica 8 dispõe acerca da necessidade da contratação de vacinas no geral, sem abordar especificamente a aquisição da vacina fornecida pelo Instituto Butantan, já a Nota Técnica 9, aborda de forma muito simplista os aspectos relacionados à vacina em questão. Recomenda-se a sua complementação.

88. No que tange ao quantitativo a ser contratado, recomenda-se analisar sob o ponto de vista do risco em relação à efetividade da vacina, tendo em vista que não há certeza quanto ao número de doses necessárias para imunização da população.

b) Previsão de Recursos Orçamentários

89. A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal, conforme dispõe o artigo 10, IX, Lei 8.429, de 1992, e artigos 38 e 55 da Lei nº 8.666, de 1993.

90. Atente-se que compete ao órgão verificar a aplicabilidade da Orientação Normativa n. 52. do Advogado-Geral da União, a fim de dispensar a necessidade da declaração acerca dos arts. 16 e 17 da LC 101, de 2000:

> As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da lei complementar nº 101, de 2000.

91. No caso dos autos, consta nos autos a emissão do respectivo empenho (Notas de empenho 7 e 8 de 2021 - 0018499560; 0018499577) , em consonância com o art. 58 da lei 4.320/64 e com a jurisprudência do TCU: "observância das fases da despesa pública, de modo que o empenho seja prévio ou contemporâneo à contratação, consoante artigos 58 a 70 da Lei nº 4.320/1964". (TCU, Acórdão nº 1.404/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.03.2011.)

c) Designação dos agentes competentes para o presente feito

92. Recomendamos ainda, que a área competente faça constar na instrução do processo as publicações dos atos de nomeação/designação, ou a citação destes, da autoridade e demais agentes administrativos, bem como dos atos normativos que estabelecem as respectivas competências para atuarem no feito, a fim de que, em caso de futura auditoria, reste comprovado nos autos, desde já, que os atos processuais foram praticados por aqueles que efetivamente detinham as atribuições correspondentes, o que recomenda a adoção de providências.

ANÁLISE DAS MINUTAS

A- Termo de Referência simplificado

93. De acordo com o art. 6º, §1º da Medida Provisória 1.026/2021, o termo de referência ou projeto básico simplificado conterá:

> I - declaração do objeto;
> II - fundamentação simplificada da contratação;
> III - descrição resumida da solução apresentada;
> IV - requisitos da contratação;
> V - critérios de medição e de pagamento;
> VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
> a) Portal de Compras do Governo Federal;
> b) pesquisa publicada em mídia especializada;
> c) sites especializados ou de domínio amplo;
> d) contratações similares de outros entes públicos; ou
> e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
> VII - adequação orçamentária.

94. Oportuno salientar que o projeto básico deverá ser elaborado pelo setor requisitante do objeto da contratação, com posterior aprovação pela autoridade competente (art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei n.° 8.666/1993).

95. Nesse contexto, em análise eminentemente formal, verifica-se que o projeto básico não contemplou o conteúdo mínimo fixado no art.6º da MP 1.026/2021. Isso porque, conforme apontado em tópico anterior, falta no documento, a estimativa de preços de que trata o inciso VI.

96. Ademais, e apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, à própria Administração, **constata-se a necessidade de atendimento adicional às recomendações abaixo, a saber:**

97. **Reformulação do item 3 , tendo em vista que não contém a descrição da solução,mas justificativa da aquisição.**

98. **Quanto ao item 4.3 , sugere-se ressalvar a primeira entrega quanto à necessidade de encaminhamento de ofício com 30 dias antes da data de entrega, considerando que faltam menos de 30 dias para a data da primeira entrega.**

99. **Quanto ao item 4.10.6 avaliar tecnicamente se o prazo mínimo exigido para validade é suficiente, tendo em vista que as vacinas poderão ser entregues antes da autorização de uso emergencial.**

100. **Na cláusula 10.1 sugere-se a inclusão de subclásula para regular o prazo de pagamento para notas fiscais entregues antes do registro na ANVISA.**

B- Termo de Contrato

101. Quanto ao instrumento contratual, o art. 12 da Medida Provisória 1.026/2021 assim prevê:

> Art. 12. O contrato ou o instrumento congênere para aquisição ou fornecimento de vacinas contra a **covid-19**, firmados antes ou após o registro ou a autorização de uso emergencial concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, poderá estabelecer as seguintes cláusulas especiais, desde que representem condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço:
>
> I - o eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado;
>
> II - hipóteses de não penalização da contratada; e
>
> III - outras condições indispensáveis para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço.
>
> § 1º Quanto às cláusulas dos contratos e instrumentos de que trata o **caput**, aplica-se o disposto na Lei nº 8.666, de 1993, no que couber.
>
> § 2º As cláusulas de que trata o **caput** são excepcionais e caberá ao gestor:
>
> I - demonstrar que são indispensáveis; e
>
> II - justificar a sua previsão.
>
> § 3º A perda do valor antecipado e a não penalização de que tratam os incisos I e II do **caput** não serão aplicáveis em caso de fraude, dolo ou culpa exclusiva do fornecedor ou contratado.
>
> § 4º Os contratos de que trata este artigo poderão ter, caso exigido pelo contratado, cláusulas de confidencialidade.
>
> § 5º Na hipótese de que trata o inciso I do **caput**, a administração pública deverá:
>
> I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e
>
> II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução, exceto na hipótese de perda do pagamento antecipado.
>
> § 6º Sem prejuízo do disposto no § 5º, a administração pública deverá prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:
>
> I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;
>
> II - a prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de1993, de até trinta por cento do valor do objeto;
>
> III - a emissão de título de crédito pelo contratado;
>
> IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da administração pública; e
>
> V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

102. Observa-se, portanto, que em regra, é aplicável o regramento geral da Lei 8.666/93 no que tange as cláusulas essenciais. Se admite a inclusão das cláusulas especiais dispostas nos incisos do art. 12 , desde que seja condição indispensável para obter o bem ou garantir a prestação do serviço. Neste sentido, o § 2º impõe ao gestor o munus de demonstrar a indispensabilidade das cláusulas e justificar a sua previsão.

103. Da análise da minuta submetida ao crivo dessa Conjur, observa-se a presença das seguintes cláusulas especiais:

1. Direito de exclusividade da União na aquisição de doses da VACINA ADSORVIDA – COVID-19 (INATIVADA), CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL, produzidas ou importadas pela Contratada em todo o território nacional, enquanto durar a pandemia, nos termos dos itens 1.3 a 1.5 da minuta.
2. Opção de aquisição prevista no item 1.6

104. Não se verificou nos autos a justificativa a contemplar a demonstração da indispensabilidade das cláusulas especiais previstas, o que recomendamos que seja sanado.

105. No que tange à opção de aquisição especificamente, recomendamos avaliar a possibilidade de substituição da cláusula pela previsão de acréscimo em até 50% do quantitativo. Isso porque, entendemos que caso a referida previsão seja utilizada para permitir aquisição em quantitativo maior que 50% , constituiria em verdadeira burla ao limite imposto pelo art. 9º da Medida Provisória 1.026 de 2021. No entanto, se o intuito da previsão for apenas garantir futuro contrato a ser firmado por meio de nova dispensa de licitação, entendemos pela possibilidade da previsão, desde que, repita-se, haja justificativa que demonstre sua imprescindibilidade. Nesse último sentido, recomendamos que a cláusula seja revista de modo a restar claro que a nova aquisição será realizada por meio de procedimento próprio, inclusive sendo objeto de novo contrato.

106. Apesar de o artigo 12 , III conter previsão genérica acerca da possibilidade de outras cláusulas especiais, entendemos que a previsão específica do art. 9º constitui vedação de aquisição em quantitativo superior à 50% do inicialmente contratado.

107. Da análise do termo de contrato acostado, tem-se as seguintes considerações:

108. No preâmbulo, recomenda-se a exclusão da fundamentação no inciso XXXIV, Artigo 24 da Lei 8.66/93, tendo em vista que a dispensa analisada fundamenta-se exclusivamente no art. 2º, inciso I da MP 1.026. Recomenda-se a seguinte redação:

> A **UNIÃO**, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0008-51, neste ato representado por seu Diretor, Sr. **ROBERTO FERREIRA DIAS**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 152.991.800, expedida pela SSP/PR, e CPF sob o nº 086.758.087-98, em conformidade com a Portaria nº 262, publicada no dia 09 de janeiro de 2019, o Diário Oficial da União nº 6, doravante denominada CONTRATANTE, e a **FUNDAÇÃO BUTANTAN**, inscrita no CNPJ nº 61.189.445/0001-56, sediada na Avenida Vital Brasil, nº 1.500, São Paulo, CEP: 05.503-900, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **RUI CURI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 53.575.963-0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 390.443.009-20, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 25000.002031/2021-69, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, por meio da **Dispensa de Licitação n° 01/2021**, com fundamento no art. 2º, inciso I da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

109. Acerca das demais disposições tem-se as seguintes considerações:

- Quanto aos itens 9.1 a 9.3 recomenda-se a alteração, de modo a prever que os acréscimos e supressões são regulados conforme o art. 9º da MP 1.026 de 2021 (que prevê o limite de 50% para acréscimos e supressões, conforme abordado em tópico próprio.
- Quanto à cláusula décima recomenda-se a adoção das previsões constantes no Modelo de Projeto Básico da AGU para compras por dispensa (Modelos Covid-19 Lei nº 14.035/20))[1] cujo teor colacionamos:

> **Nota explicativa**: em caso de remessa parcelada, discriminar as respectivas parcelas, prazos e condições.

Nota explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada.

O prazo de entrega dos bens é de ..... dias, contados do(a) ....., em remessa *(única ou parcelada)*, no seguinte endereço .....

No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a ..... (.....) (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de .....(.....) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de .... (...) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de .....(.....) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- Sugere-se a inclusão da possibilidade de rescisão do contrato, sem qualquer ônus para a contratante, não sendo devido, sequer, o pagamento pelas parcelas eventualmente entregues, no caso em que a contratada não consiga a autorização para uso emergencial junto a Anvisa. Além disto, sugere-se a inclusão de hipótese de rescisão caso após a autorização para uso emergencial e antes da completa execução do contrato, a ANVISA não registre o produto e revogue a autorização para uso emergencial. Neste caso, recomenda-se que não haja ônus para a contratante em relação às doses ainda não entregues. Já em relação às doses entregues, recomenda-se avaliar a possibilidade de que a contratante seja indenizada em razão das doses entregues mas ainda não administradas.Recomenda-se que tais cláusulas sejam inseridas, também, na matriz de riscos, nos termos do artigo 5º da MP.
- Seja regulado no contrato e na matriz de risco, o destino a ser dado em caso de não ocorrência do registro na ANVISA, das doses entregues e não administradas.

110. As alterações sugeridas poderão ser efetuadas por meio de termo aditivo a ser oportunamente analisado.

CONCLUSÃO

111. Em face do exposto, manifesta-se este órgão de consultoria no sentido da viabilidade jurídica de convalidação do Contrato Administrativo nº 5, oriundo de contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 2º, I da Medida Provisória 1.026, de 6 de janeiro de 2021, condicionada ao atendimento das recomendações formuladas neste parecer, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à presente análise.

112. Registre-se, por fim, que não há determinação legal a impor a fiscalização posterior de cumprimento de recomendações feitas. Eis o teor do BPC nº 05: "*Ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juízo conclusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha sugerido as alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verificação do cumprimento das recomendações consignadas*".

À consideração superior.

Brasília, 07 de janeiro de 2021.

ADRIELE MATOS DE SANTANA SANTOS
Advogada da União
Coordenadora de Suporte Jurídico em Procedimentos Licitatórios
COJUPLI/GLICI/CONJUR-MS

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Notas

1. ^ *https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/covid-19-lei-no-14-035-20*

Documento assinado eletronicamente por ADRIELE MATOS DE SANTANA SANTOS, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558317043 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ADRIELE MATOS DE SANTANA SANTOS. Data e Hora: 08-01-2021 10:31. Número de Série: 129088775082263445319940945. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE JURÍDICA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

DESPACHO n. 00071/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO BUTANTAN
ASSUNTOS: COVID-19

1. Aprovo o PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, da Advogada da União Adriele Matos De Santana Santos, sem, contudo, promover a reanálise integral dos autos, mesmo porque a atribuição desta Coordenação-Geral restringe-se à aprovação da tese jurídica versada na manifestação em apreço, com vistas à uniformidade de atuação da Consultoria Jurídica.

2. De forma complementar faço as seguintes considerações.

3. Quanto as considerações feitas no parágrafo 102 e seguintes da manifestação aprovada faço as seguintes considerações complementares. Quanto à cláusula de "opção de aquisição" reforço que tal cláusula deverá ser entendida, apenas, como a obrigação unilateral da contratada de garantir a disponibilidade do quantitativo mencionado para eventual e futura aquisição da União, desde que o direito seja exercido em observância ao pactuado.

4. Além disto, reforço que para realizar tal aquisição eventual será necessária nova instrução de processo autônomo de compra e o preenchimento de todos os requisitos para a realização de nova aquisição por parte da União. Não é possível entender tal cláusula como a possibilitar o acréscimo contratual superior ao limites legais.

5. Reitero, também, a necessidade de observância do disposto no artigo 5º, *caput,* da Medida Provisória nº 1.026/2020.

6. De tal forma, sugere-se o retorno dos autos ao Departamento de Logística em Saúde para que promova os ajustes recomendados.

7. À consideração superior.

Brasília, 08 de janeiro de 2021.

RAFAEL CARRAZZONI MANSUR
Advogado da União
Coordenador-Geral de Análise Jurídica de Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres
CGLICI/CONJUR-MS

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CARRAZZONI MANSUR, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558737281 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL CARRAZZONI MANSUR. Data e Hora: 08-01-2021 11:22. Número de Série: 690785941506462694337883756 83. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, 6º ANDAR, BRASÍLIA/DF, CEP 70058-900

DESPACHO n. 00072/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU

NUP: 25000.002031/2021-69
INTERESSADA: Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS.
ASSUNTO: Contrato Administrativo nº 05/2021. Aquisição de doses da VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA). Convalidação.

1. Aprovo o PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, da lavra da Coordenadora de Suporte Jurídico em Procedimentos Licitatórios, a Advogada da União Adriele Matos de Santana Santos, com a complementação constante no DESPACHO n. 00071/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, subscrito pelo Coordenador-Geral de Análise Jurídica de Licitações, Contratos e Instrumentos Congêneres, o Advogado da União Rafael Carrazzoni Mansur, ambos de 08/01/2021, adotando seus fundamentos e conclusões.

2. Recomenda-se especial atenção aos itens 23 a 25, 33/34, 44 a 47, 55, 59 a 62, 64 a 67, 74/75, 86 a 88, 92, 94 a 100, 103/104, 105/106, 108, 109 e 110 todos do PARECER n. 00013/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU, bem como à integra do DESPACHO n. 00071/2021/CONJUR-MS/CGU/AGU.

3. Pelo exposto, ao Apoio Administrativo desta Consultoria Jurídica, para que:

- **a)** junte as presentes manifestações ao sistema SEI e encaminhe os autos virtuais ao Departamento de Logística em Saúde - DLOG/SE/MS, para ciência do opinativo e demais providências cabíveis; e
- **b)** arquive o processo em epígrafe no sistema SAPIENS.

Brasília, 08 de janeiro de 2021.

JÚLIO CÉSAR ALVES FIGUEIRÔA
Advogado da União
Consultor Jurídico Adjunto
Consultor Jurídico junto ao Ministério da Saúde, Substituto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25000002031202169 e da chave de acesso f5a873b0

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558759794 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA. Data e Hora: 08-01-2021 12:32. Número de Série: 13813281. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.